

0002404-27.2022.8.26.0366

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME PINHO RIBEIRO

Comarca: Mongaguá

Foro: Foro de Mongaguá

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... ao crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06), trata-se de delito de natureza formal e permanente, que se caracteriza pela associação entre 2 (duas) ou mais pessoas para o tráfico (reiteradamente ou não), em vínculo dotado de duas características: (1) estabilidade e (2) permanência. Assim, a associação se distingue do simples concurso de crimes, que pode ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mongaguá

Foro de Mongaguá

1ª Vara

Avenida São Paulo, 300, Mongaguá-SP - cep 11730-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0002404-27.2022.8.26.0366 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002404-27.2022.8.26.0366

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - H04459-1 - Delegacia Seccional de Policia de Itanhaém

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS ALVES SOARES e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME PINHO RIBEIRO

Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de LUCAS ALVES SOARES e FERNANDO CARLOS RIBEIRO SCHIAVONE, já qualificado nos autos, na qual lhe imputa a prática do crime descrito no artigo 33, caput, artigo 35, caput, ambos da Lei n. 11.343/06, bem como nos artigos 329, caput, e artigo 129, parágrafo 12, na forma do artigo 70, Código Penal, todos na forma do artigo 69, Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 09 de outubro de 2022, por volta das 21h00, na Avenida Jussara, n. 1584, Balneário Jussara, nesta comarca de Mongaguá, os acusados associaram-se a um terceiro indivíduo não identificado, para o fim de praticar, reiteradamente, o crime descrito no art. 33, caput da Lei n. 11.346/06. Consta também que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os acusados preparavam,

tinham e depósito e guardavam, para fins de tráfico, sem autorização, 407 porções de maconha, 1.624 porções de crack, 33 porções de haxixe e 4.238 porções de cocaína. Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, os acusados se opuseram à execução de ato legal, mediante violência aos policiais militares Alexandre Fernando Carneiro, Darlan de Aguiar Vaz e Moizés dos Santos. Consta, por fim, que nestas mesmas circunstâncias de tempo e local, os acusados ofenderam a integridade corporal dos policiais Alexandre Fernando Carneiro, Darlan de Aguiar Vaz e Moizés dos Santos, durante o exercício de suas funções.

Audiência de custódia realizada em 10 de outubro de 2022, momento em que homologada a prisão em flagrante e convertida em preventiva, bem como recebida a denúncia (fls. 89/92).

Citados, os denunciados apresentaram resposta à acusação (fls. 120/122).

Não constatada hipóteses de absolvição sumária, nos termos do art. 397 do Código de Processo Penal (fls. 127/128 e fls. 131/132), designou-se audiência de instrução e julgamento, na qual foi produzida a prova oral requerida pelas partes e, após, procedeu-se ao interrogatório (fls. 176/177). Não houve requerimento de diligências complementares (CPP, art. 402).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos exatos termos da denúncia. As defesas técnicas dos acusados corroboraram em parte a manifestação do órgão ministerial, mas pugnaram pela absorção do crime de lesão corporal pelo de resistência, fixação do regime inicial semiaberto.

É o relatório. Fundamento e decido.

Não há questões preliminares a serem analisadas, tampouco vícios processuais a serem sanados. Não se implementou prazo prescricional, tampouco outra causa extintiva de punibilidade no curso da persecução penal. Resta, por conseguinte, o exame do mérito.

A materialidade dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06), e resistência (art. 329 do Código Penal) está suficientemente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), pelo auto de exibição/apreensão (fls. 12), pelo laudo de exame pericial preliminar (fls. 13), laudo pericial definitivo (fls. 138/141), bem como pelos depoimentos colhidos em juízo, conforme ata e mídia.

Quanto à autoria dos acusados, a testemunha Alexandre Fernando Carneiro, policial militar, narrou que (a) receberam uma denúncia anônima acerca da traficância no local, (b) montaram uma operação com duas equipes, se deslocando até lá, (c) se aproximaram da residência, visualizando um indivíduo no portão social (havia um da garagem), tendo ele empreendido fuga, pulando os muros, (d) do próprio portão, que ficou aberto, já foi possível visualizar ambos os acusados sentados no chão, contando droga e dinheiro, (e) Lucas se levantou e tentou retirar a arma das mãos de um dos policiais, acarretando pancadaria generalizada, até a contenção dos indivíduos, (f) após, tudo já mais calmo, Fernando informou que a casa era dele, e Lucas o estava ajudando no manejo e contabilidade das drogas.

Já a testemunha Darlan de Aguiar Vaz, policial militar, disse que (a) compõe a equipe da força tática da Polícia Militar, (b) recebeu informação, por ser morador da região, que no local em apreço estava tendo uma contagem de drogas, (c) transmitiu a notícia recebida ao sargento Alexandre, e foram até o endereço, (d) lá chegando, havia um rapaz na porta, que gritou “moiou” e saiu correndo, (e) avistaram na garagem dois indivíduos sentados no chão fazendo a contagem de drogas e dinheiro, (f) ao perceberem a presença dos policiais, tentaram se evadir, e reagiram à abordagem, sendo necessário o uso da força policial necessária, (g)

havia bastante droga, cocaína, maconha, crack, haxixe e dinheiro, (h) os acusados partiram para cima dos policiais, tendo um deles tentado pegar a arma que estava nas mãos do declarante, (i) sofreu lesões no braço e tornozelo esquerdo, (j) no momento da prisão, Fernando disse que o local era sua residência, e que era utilizado para a contabilidade e distribuição de entorpecentes, (k) realizadas diligências no imóvel, nada mais de ilícito foi encontrado.

A testemunha Moizés dos Santos, policial militar, narrou que (a) estava de serviço e receberam denúncia de que indivíduos estavam traficando no referido endereço, (b) dirigiram-se ao local e, com a aproximação da equipe, um indivíduo que estava na calçada, empreendeu fuga, deixando o portão aberto, (c) chegaram na garagem, firam os dois acusados fazendo contagem de drogas, momento em que dada voz de prisão, (d) os dois acusados investiram contra os policiais, que se utilizaram da força para a contenção, (e) Lucas, inclusive, tentou pegar a arma de um dos policiais, (f) teve escoriações e corte no supercílio, em razão de um soco desferido por Lucas, (g) havia grande quantidade de droga, diversas, além de uma quantia em dinheiro.

O acusado Lucas Alves Soares alegou que (a) os fatos são verdadeiros, menos a parte que diz que foi para cima da arma de um dos policiais, (b) de fato, se debateu, para se soltar, mas não para agredir, (c) estava na rua de casa, depois foi para a casa do Fernando, pois haveria a "troca de plantão" para a comercialização de drogas, momento em que os policiais chegaram, (d) ficou 05 anos preso, estava desesperado, mas infelizmente acabou se deparando com esse erro novamente, (e) quando da abordagem, se encontravam no quarto da frente, ao lado da garagem, sentados na cama, (f) ao perceber a presença policial, tentou fugir pela própria porta em que eles entraram, tendo se debatido, (g) a abordagem não ocorreu com agressões dos policiais de início, mas tão somente quando já estavam imobilizados e algemados, (h) o portão da casa estava aberto.

O acusado Fernando Carlos Schiavone alegou que (a) os fatos são verdadeiros, com exceção das alegadas agressões sofridas pelos policiais, (b) havia um terceiro indivíduo, conhecido como olheiro, (c) estava juntamente com Lucas, contando droga e dinheiro, (d) não estavam na garagem, mas sim no interior da casa, estando o portão aberto, (e) quanto à disposição do imóvel, adentrando a casa, tem uma garagem, que tem uma porta do quarto, saída da garagem, fora o corredor, (f) o primeiro cômodo é um banheiro com quarto, local em que estavam sentados na cama, (g) os policiais já chegaram dando voz de prisão e batendo neles, sendo esta a razão que tentaram empreender fuga, (h) se a abordagem fosse comum, não tentariam reagir, (i) Lucas fugiu pela mesma porta que eles [os policiais] entraram, (j) os machucados nos policiais podem ter sido da tentativa de fuga, (k) caiu nessa vida porque estava precisando, sendo usuário de droga.

Quanto ao valor probatório a ser conferido ao depoimento dos policiais que atuaram na repressão imediata à infração penal, é oportuno obtemperar que tal atuação na fase de investigação não implica óbice à oitiva de tais agentes públicos na instrução processual (STF, RHC 108/586, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 9/8/2011).

Assim, as declarações do policial (ou de outros agentes públicos) têm natureza de depoimento testemunhal e, por conseguinte, devem ser valoradas à luz de sua capacidade para depor e da ausência de causas de impedimento ou suspeição. O cargo público ocupado, por si só, não confere maior ou menor valor probatório ao depoimento prestado em juízo.

Assim, é indispensável verificar a sua coesão interna e a sua coerência externa com os demais elementos probatórios colhidos no curso da persecução penal, a fim de sopesar o valor probatório que lhe deve ser atribuído. Portanto, em suma, "os depoimentos de policiais devem ser analisados sob o mesmo prisma de qualquer outra testemunha, não tendo seu valor diferenciado pelo fato de serem servidores

públicos" (TJSP; Apelação Criminal 1502002-10.2019.8.26.0548; Rel. Des. Guilherme de Souza Nucci; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 27/04/2020), e é necessário observar o "seu teor como a qualquer outra testemunha ouvida nos autos, desde que não contrariada por outros elementos de prova" (TJSP; Apelação Criminal 1500121-45.2020.8.26.0618; Rel. Des. Camargo Aranha Filho; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 20/04/2021).

No mesmo sentido se inclina a jurisprudência de ambas as Turmas que integram a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (com competência para julgamento de matéria penal e processual penal): STJ, HC 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2016; STJ, HC 166979/SP. Min. Rel. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 15.08.2012).

Assim, o resultado conjunto das provas coletadas durante a instrução processual é suficiente considerar que os acusados concorreram para a prática do tráfico de drogas. Verifica-se, pois, que o depoimento dos policiais é uníssono quanto à abordagem de ambos os acusados, no interior da residência de Fernando, realizando a contagem de grande quantidade de drogas, bem como de moeda corrente em espécie. Ademais, os réus confessaram a prática do delito de traficância, tendo Lucas dito, inclusive, que estava na casa de Fernando para a "troca de turnos".

Quanto à tipicidade, cumpre notar que o crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo (ação múltipla) e pode ser consumado por meio da execução de um dos 18 (dezoito) núcleos do tipo constantes do art. 33 da Lei n. 11.343/06, alguns dos quais de natureza instantânea e outros de natureza permanente. Muito embora a comercialização da droga não seja a única conduta tipificada no referido tipo misto, é preciso reconhecer que o aludido crime possui um elemento implícito, qual seja, a destinação da droga (objeto material do crime) à comercialização ilícita, notadamente ante o cotejo entre tal tipo penal e aqueles tipificados nos arts. 28 (tipo caracterizado pela destinação da droga ao uso próprio) e art. 33, § 3º, da mesma lei (tipo caracterizado pela destinação da droga ao consumo conjunto e gratuito). O elemento caracterizador do tráfico consiste na vontade de os agentes verem a droga transferida ou colocada na posse de usuários (entrega ao consumo), traduzida em qualquer um dos dezoito verbos da descrição típica, entre estes, o de "ter em depósito", como no caso dos autos.

Assim, a execução isolada e independente de qualquer das dezoito condutas descritas no art. 33 da Lei n. 11.343/06, desde que orientada à comercialização ilícita da droga, configura o crime de tráfico de drogas.

A tipicidade da conduta, por força da teoria da indiciabilidade (*ratio cognoscendi*) acarreta a presunção (relativa) de sua ilicitude. Esta, por sua vez, não foi afastada pela demonstração de circunstâncias aptas a gerar dúvida razoável quanto à configuração de qualquer excludente (legal ou supralegal) de ilicitude. De outro lado, quanto à culpabilidade, observa-se que os agentes são imputáveis e que não estão demonstradas causas de exclusão do potencial conhecimento da ilicitude do fato ou da exigibilidade de conduta diversa. Assim, não foram comprovadas causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.

Assim, constata-se que os acusados praticaram conduta típica e ilícita pela qual é culpável, de modo que, preenchidos os três estratos do conceito analítico de crime, mostra-se imperativa a condenação penal.

Quanto ao crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06), trata-se de delito de natureza formal e permanente, que se caracteriza pela associação entre 2 (duas) ou mais pessoas para o tráfico (reiteradamente ou não), em vínculo dotado de duas características: (1) estabilidade e (2) permanência. Assim, a associação se distingue do simples concurso de crimes, que pode ser pontual e eventual em relação a apenas um crime, em razão dessas duas notas características do crime associativo.

A efetiva consumação do tráfico de drogas pelos associados (especial fim de agir), por outro lado, não é indispensável para a consumação do crime - trata-se de mero exaurimento.

Sobre tais aspectos, por todos, cf. STJ, HC: 212000/SP 2011/0153618-2, Quinta Turma, DJe 19/11/2013; TJSP, Apelação Criminal 1514059-16.2020.8.26.0228; 7ª Câmara de Direito Criminal; j. 05/08/2021; TJSP; Apelação Criminal 1500516-96.2018.8.26.0621; 4ª Câmara de Direito Criminal; j. 02/08/2021; TJSP; Apelação Criminal 1531240-64.2019.8.26.0228; 16ª Câmara de Direito Criminal; j. 24/07/2021).

No caso ora em apreço, verifica-se que, apesar dos indicativos da vinculação eventual dos acusados para a prática do crime de tráfico de drogas, as provas produzidas no curso da instrução processual não se mostraram suficientes para demonstrar, para além de dúvida razoável, a existência de um vínculo estável e permanente entre os acusados para a comercialização ilícita de drogas.

Com efeito, a rigor, o presente processo penal está instruído exclusivamente pelos elementos probatórios colhidos pela autoridade policial quando surpreendidos e presos em flagrante os acusados - após suposta "denúncia anônima -, em uma única data e oportunidade, sem que tenham sido realizadas diligências anteriores ou posteriores que pudessem atestar, com elevado grau de probabilidade e segurança, o vínculo associativo prévio para a prática do tráfico.

Veja-se que não foram apreendidos outros objetos indicativos da estabilidade e permanência do vínculo, tais como mensagens, anotações, planilhas ou outros objetos e documentos indicativos da associação pretérita. De outro lado, não houve quebras de sigilo ou interceptações telefônicas/telemáticas a revelar o vínculo anterior dos acusados entre si para a prática do tráfico e assim viabilizar a condenação. Assim, apesar de as provas colhidas indicarem que os acusados estavam sim traficando drogas juntos, essa reunião configura mera coautoria, ao passo o acervo de elementos de informação e prova é bastante limitado e não permite a aferição do vínculo associativo estável e permanente na forma do tipo penal descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/06.

Ausente a comprovação da estabilidade e da permanência, a absolvição por insuficiência probatória se impõe.

Quanto ao delito de resistência, entendo suficientemente demonstrada sua prática pelos acusados. Os policiais militares foram uníssomos na narrativa de que ao serem surpreendidos pela guarnição, os réus resistiram à prisão, buscando a fuga da prisão em flagrante. Inclusive, houve confissão da conduta por Lucas, que disse expressamente ter corrido em direção à porta e se debatido quando da prisão. No mesmo sentido, o acusado Fernando disse que "se a abordagem fosse comum, não tentariam resistir". Assim, cabível a condenação perquirida pelo órgão de acusação.

Por fim, quanto aos crimes de lesões corporais, não existem elementos que comprovem a materialidade delitiva. Explico. Os prontuários médicos colacionados a fls. 30/33 são ilegíveis. Com a devida vênia ao n. Médico, não se mostra possível a compreensão das palavras lançadas nas fichas de atendimento ambulatorial. Quanto aos laudos produzidos pelo IML (fls. 165/168), no dia seguinte aos fatos narrados na denúncia, constata-se do campo "discussão e conclusão" que "não há no momento deste exame, lesões corporais recentes de interesse médico legal". Concluo, portanto, que a absolvição é medida jurídica cabível no presente caso, em razão da inexistência de provas suficientes da materialidade delitiva.

Logo, deve ser promovida a condenação de ambos os acusados tão somente pelos crimes de tráfico de drogas e resistência.

Quanto a causas modificativas da pretensão punitiva, verifica-se que o acusado

Lucas Alves Soares é multireincidente específico no crime de tráfico de drogas (76/79), incidindo a agravante prevista no art. 61, I, CP. Por outro lado, Fernando Carlos Ribeiro Schiavone é tecnicamente primário. Ambos confessaram a prática dos crimes de tráfico de drogas e de resistência, incidindo a atenuante positivada no art. 65, III, "d", CP.

Quanto à causa especial de diminuição de pena constante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a sua incidência depende do preenchimento de quatro requisitos cumulativos: (1) primariedade, (2) bons antecedentes, (3) não dedicação a atividades criminosas e (4) não integração a organização criminosa.

No caso, a folha de antecedentes de Lucas aponta duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, fato que, por si só, afasta a minorante em apreço.

Embora não haja elementos suficientes para a condenação dos acusados como incursos no crime tipificado no art. 35 da Lei de Drogas, entendo que a quantidade da droga apreendida (407 porções de maconha, 1.624 porções de crack, 33 porções de haxixe e 4.238 porções de cocaína), assim como as condições em que se deram a prisão, em momento em que Lucas e Fernando faziam a "troca de turno" para a traficância, entendo que há "dedicação a atividades criminosas", fato que justifica o afastamento da causa de diminuição da pena contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas para ambos os acusados.

Passa-se então à aplicação da pena, com base nas diretrizes constantes dos arts. 59 e 68 do CP e do art. 42 da Lei n.11.343/06, à luz do princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI).

- Lucas Alves Soares: artigo 33, caput, Lei n. 11.343/06.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Constatado que a quantidade da droga apreendida se mostra suficiente para valoração na presente fase, pois consistente em 407 porções de maconha, 1.624 porções de crack, 33 porções de haxixe e 4.238 porções de cocaína. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 76/79 aponta mais de uma condenação com trânsito em julgado, plenamente possível a valoração negativa neste primeiro momento. Em relação às outras circunstâncias judiciais, não há elementos aptos à valoração negativa. Portanto, considerando duas circunstâncias negativas, fixo a pena base em 07 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 750 dias-multa.

Segunda etapa. Constata-se que o acusado é reincidente, portanto, incide a agravante constante do art. 61, I, CP. Ocorre que o acusado confessou integralmente a prática do crime em Juízo, incidindo a atenuante constante do art. 65, III, "d", CP. Procedo a compensação integral entre agravante e atenuante, em consonância à jurisprudência consolidada no âmbito do C. STJ (Sexta Turma. HC n. 714505/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, j. em 23 de agosto de 2022). Por esta razão, mantenho a pena intermediária no patamar anteriormente fixado, qual seja, 07 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 750 dias-multa.

Terceira etapa. Não há causas de diminuição ou aumento de pena. Portanto, fica estabelecida a pena definitiva em 07 anos e 06 meses de reclusão, além do pagamento de 750 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve ser atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo

pagamento.

Regime de cumprimento de pena e o tempo de prisão provisória. O sentenciado é reincidente, tendo praticado o crime ora em análise quando ainda estava em cumprimento da pena anterior. Bem por isso, com base no art. 33, §2º, "b", do CP, estabelece o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena. Eventual tempo de prisão cautelar não interfere na fixação do regime prisional - art. 387, §2º, do CPP.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, bem como da reincidência específica e circunstâncias judiciais negativas.

- Lucas Alves Soares: artigo 329, caput, Código Penal.

Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 76/79 aponta mais de uma condenação com trânsito em julgado, plenamente possível a valoração negativa neste primeiro momento. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Quanto às circunstâncias do crime, constato existirem elementos aptos à valoração negativa nesta etapa, pois o acusado chegou a entrar em luta corporal com os policiais, inclusive tentando pegar a arma de fogo ostentada por um dos agentes. Os motivos da infração penal são inerentes à espécie delitiva. As consequências da infração penal não comportam valoração negativa. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto aos critérios para a fixação da pena-base (CP, art. 59, II), tal atividade jurisdicional não está adstrita a etapas puramente aritméticas, com a estrita vinculação a bases de cálculo e frações de acréscimo obrigatórias, mas sim deve observar o princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI), o dever de fundamentação das decisões judiciais (CR/88, art. 93, IX) e o dever de isonomia (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º).

Logo, exige-se um juízo racionalmente fundamentado de coerência entre o intervalo abstratamente previsto entre a pena mínima e a pena máxima (premissa maior), a quantidade e natureza das circunstâncias judiciais avaliadas (premissa menor) e a exasperação da pena promovida (conclusão). Nesse sentido, por todos, cf. STJ, AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Sexta Turma, DJe 11/03/2021. De todo modo, diante da inexistência de critério legal positivado, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o referencial básico de exasperação da pena mínima (base de cálculo) em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima por cada circunstância judicial negativa (fração de acréscimo): "a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo", admitida a aplicação de fração diversa "diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). No mesmo sentido: STJ, HC 605.628/SP, Quinta Turma, DJe 08/04/2021; AgRg no HC 548.785/RJ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020; HC 585.748/CE, Sexta Turma, DJe 10/02/2021. A corroborar tal critério, cf. ainda: TJSP; Apelação Criminal 1500855-04.2020.8.26.0583; 2ª Câmara de Direito Criminal; j. 31/05/2021; TJSP; Apelação Criminal 0000505-83.2018.8.26.0123; 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 11/12/2020; TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0012086-82.2016.8.26.0635; 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 28/02/2019; TJSP; Apelação Criminal 0004418-97.2015.8.26.0052; 6ª Câmara de Direito Criminal; j. 30/08/2018.

À luz de tal diretriz, no caso, ante a valoração das duas circunstâncias judiciais supra, acresce-se a pena mínima em 2/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, a resultar na pena-base de 07 meses e 15 dias de detenção.

Segunda etapa. Constata-se que o acusado é reincidente, portanto, cabível a agravante constante do art. 61, I, CP. Ocorre que o acusado confessou integralmente a prática do crime em Juízo, incidindo a atenuante constante do art. 65, III, "d", CP. Procedo a compensação integral entra agravante e atenuante, em consonância à jurisprudência consolidada no âmbito do C. STJ (Sexta Turma. HC n. 714505/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, j. em 23 de agosto de 2022). Por esta razão, mantenho a pena intermediária no patamar anteriormente fixado, qual seja, 07 meses e 15 dias de detenção.

Terceira etapa. Não há causas de diminuição ou aumento de pena. Portanto, fica estabelecida a pena definitiva em 07 meses e 15 dias de detenção.

Regime de cumprimento de pena e o tempo de prisão provisória. O sentenciado é reincidente, havendo circunstâncias judiciais negativas na primeira fase. Bem por isso, com base no art. 33, caput, c/c §2º, "b", c/c §3º do CP, estabeleço o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena. Eventual tempo de prisão cautelar não interfere na fixação do regime prisional - art. 387, §2º, do CPP.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista a reincidência do acusado em crimes dolosos, bem como as circunstâncias judiciais negativas.

- Fernando Carlos Ribeiro Schiavone: artigo 33, caput, Lei n. 11.343/06.

Primeira etapa. Ao analisar as circunstâncias judiciais, anoto que, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, são preponderantes nesta fase a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Constato que a quantidade da droga apreendida se mostra suficiente para valoração na presente fase, pois consistente em 407 porções de maconha, 1.624 porções de crack, 33 porções de haxixe e 4.238 porções de cocaína. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 82/83 aponta a primariedade técnica e bons antecedentes do acusado. Em relação às outras circunstâncias judiciais, não há elementos aptos à valoração negativa. Portanto, considerando uma circunstância negativa, fixo a pena base em 06 anos e 03 meses de reclusão, além do pagamento de 650 dias-multa.

Segunda etapa. Constata-se que o acusado é reincidente, portanto, incide a agravante constante do art. 61, I, CP. Ocorre que o acusado confessou integralmente a prática do crime em Juízo, incidindo a atenuante constante do art. 65, III, "d", CP. Procedo a compensação integral entra agravante e atenuante, em consonância à jurisprudência consolidada no âmbito do C. STJ (Sexta Turma. HC n. 714505/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, j. em 23 de agosto de 2022). Por esta razão, mantenho a pena intermediária no patamar anteriormente fixado, qual seja, 06 anos e 03 meses de reclusão, além do pagamento de 650 dias-multa.

Terceira etapa. Não há causas de diminuição ou aumento de pena. Portanto, fica estabelecida a pena definitiva em 06 anos e 03 meses de reclusão, além do pagamento de 650 dias-multa.

Quanto ao valor do dia-multa, à luz dos arts. 49, § 1º, e 60 do CP, deve ser fixado no seu grau mínimo, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento, já que, ao que consta dos autos, o réu não auferia renda superior a um salário mínimo. A pena deve atualizada pelo INPC/IBGE, refletido na Tabela Prática do TJSP, até o efetivo pagamento.



Regime de cumprimento de pena e o tempo de prisão provisória. Embora tecnicamente primário, as circunstâncias judiciais preponderantes, na primeira fase, lhe foram negativas. Bem por isso, com base no art. 33, §2º, "b", do CP, estabeleço o REGIME FECHADO para o início do cumprimento da pena. Eventual tempo de prisão cautelar não interfere na fixação do regime prisional - art. 387, §2º, do CPP.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade aplicada, bem como das circunstâncias judiciais negativas.

- Fernando Carlos Ribeiro Schiavone: artigo 329, caput, Código Penal. Na primeira fase, a culpabilidade (grau ou nível de reprovabilidade da conduta) não transcende aquela inerente à conduta típica praticada. Quanto aos antecedentes, a certidão de fls. 82/83 aponta a primariedade técnica e bons antecedentes do acusado. Em relação à conduta social e à personalidade, trata-se de circunstâncias subjetivas para cuja valoração não há elementos nos autos. Quanto às circunstâncias do crime, constato existirem elementos aptos à valoração negativa nesta etapa, pois o acusado chegou a entrar em luta corporal com os policiais, inclusive tentando pegar a arma de fogo ostentada por um dos agentes. Os motivos da infração penal são inerentes à espécie delitativa. As consequências da infração penal não comportam valoração negativa. Por fim, em relação ao comportamento da vítima, esta não contribuiu para a prática do crime.

Quanto aos critérios para a fixação da pena-base (CP, art. 59, II), tal atividade jurisdicional não está adstrita a etapas puramente aritméticas, com a estrita vinculação a bases de cálculo e frações de acréscimo obrigatórias, mas sim deve observar o princípio da individualização das penas (CR/88, art. 5º, XLVI), o dever de fundamentação das decisões judiciais (CR/88, art. 93, IX) e o dever de isonomia (CPC, art. 926, c/c CPP, art. 3º).

Logo, exige-se um juízo racionalmente fundamentado de coerência entre o intervalo abstratamente previsto entre a pena mínima e a pena máxima (premissa maior), a quantidade e natureza das circunstâncias judiciais avaliadas (premissa menor) e a exasperação da pena promovida (conclusão). Nesse sentido, por todos, cf. STJ, AgRg no AREsp 1.659.986/RS, Sexta Turma, DJe 11/03/2021. De todo modo, diante da inexistência de critério legal positivado, colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o referencial básico de exasperação da pena mínima (base de cálculo) em 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima por cada circunstância judicial negativa (fração de acréscimo): "a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo", admitida a aplicação de fração diversa "diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu" (STJ, HC 646.844/ES, Quinta Turma, DJe 09/04/2021). No mesmo sentido: STJ, HC 605.628/SP, Quinta Turma, DJe 08/04/2021; AgRg no HC 548.785/RJ, Sexta Turma, DJe 23/10/2020; HC 585.748/CE, Sexta Turma, DJe 10/02/2021. A corroborar tal critério, cf. ainda: TJSP; Apelação Criminal 1500855-04.2020.8.26.0583; 2ª Câmara de Direito Criminal; j. 31/05/2021; TJSP; Apelação Criminal 0000505-83.2018.8.26.0123; 3ª Câmara de Direito Criminal; j. 11/12/2020; TJSP; Embargos de Declaração Criminal 0012086-82.2016.8.26.0635; 8ª Câmara de Direito Criminal; j. 28/02/2019; TJSP; Apelação Criminal 0004418-97.2015.8.26.0052; 6ª Câmara de Direito Criminal; j. 30/08/2018.

À luz de tal diretriz, no caso, ante a valoração das duas circunstâncias judiciais supra, acresce-se a pena mínima em 1/8 (dois oitavos) do intervalo entre a pena mínima e a pena máxima, a resultar na pena-base de 04 meses e 22 dias de detenção.

Segunda etapa. Constata-se que o acusado é primário e confessou a prática da infração penal, incidindo a atenuante constante do art. 65, III, "d", CP. Por esta razão, fixo a pena intermediária no patamar de 03 meses e 28 dias de detenção.

Terceira etapa. Não há causas de diminuição ou aumento de pena. Portanto, fica estabelecida a pena definitiva em 03 meses e 28 dias de detenção.

Regime de cumprimento de pena e o tempo de prisão provisória. Embora primária, constata-se circunstâncias judiciais negativas na primeira fase. Bem por isso, com base no art. 33, caput, c/c §2º, "b", c/c §3º do CP, estabeleço o REGIME SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena. Eventual tempo de prisão cautelar não interfere na fixação do regime prisional - art. 387, §2º, do CPP.

Quanto à substituição por pena restritiva de direito (CP, art. 44, I) e à suspensão condicional da pena - sursis penal - (CP, art. 77), são incabíveis, tendo em vista a violência empregada no delito, bem como as circunstâncias judiciais negativas.

Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, a fim de:

- (1) ABSOLVER os acusados LUCAS ALVES SOARES e FERNANDO CARLOS RIBEIRO SCHIAVONE da imputação da prática da infração penal descrita no art. 35 da Lei n. 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do CPP;
- (2) ABSOLVER os acusados LUCAS ALVES SOARES e FERNANDO CARLOS RIBEIRO SCHIAVONE das imputações da prática da infração penal descrita no art. 129, parágrafo 12, Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do CPP
- (3) CONDENAR o acusado LUCAS ALVES SOARES ao cumprimento de 07 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 750 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33, caput, Lei n. 11.343/06;
- (4) CONDENAR o acusado FERNANDO CARLOS RIBEIRO SCHIAVONE ao cumprimento de 06 anos e 03 meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 650 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo, em razão da prática da infração penal descrita no art. 33, caput, Lei n. 11.343/06;
- (5) CONDENAR o acusado LUCAS ALVES SOARES ao cumprimento de 07 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da prática da infração penal descrita no art. 329 do Código Penal;
- (6) CONDENAR o acusado FERNANDO CARLOS RIBEIRO SCHIAVONE ao cumprimento de 03 meses e 28 dias de detenção, em regime inicial semiaberto, em razão da prática da infração penal descrita no art. 329 do Código Penal;

Quanto à manutenção da prisão cautelar, à luz do art. 387, § 1º, do CPP, cumpre notar que as razões já esposadas para a sua decretação permanecem presentes. A saber, com a prolação desta sentença foi ratificado o requisito da fumaça do cometimento do delito, ao passo que nenhum fato superveniente à aludida decisão afastou ou mesmo mitigou o perigo advindo da colocação do acusado em liberdade já antes verificado.

Não obstante, expeça-se guia provisória de execução penal, em atenção ao que determina a Súmula 716/STF, a fim de que sejam implementadas as condições do regime ora imposto (STF, HC 180957, Segunda Turma, DJe 13.05.2020, RHC 166279/SP, Segunda Turma, DJe 2.2.2020; HC 123267, Primeira Turma, DJe 02.02.2015; STF, HC 118528, Primeira Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 14.02.2014), tal como admitido também pelo STJ (RHC 12.561/GO, Quinta Turma, DJe 29.06.2020, RHC 75.051/MG, Sexta Turma, DJe 16.12.2016), salvo se da unificação de penas resultar a imposição de regime mais gravoso pelo Juízo da execução penal (LEP, art. 111, parágrafo único).

Quanto à droga apreendida, deve ser promovida a destruição das amostras eventualmente acauteladas, caso ainda não tenha sido realizada, na forma do art. 72 da Lei n. 11.343/06.

Quanto à multa, por se tratar de multa aplicada de modo cumulado, com o trânsito em julgado, expeça-se certidão da sentença, abrindo-se vista ao Ministério Público, nos termos do art. 480, NSCGJ/SP.

Custas pelos réus (CPP, art. 804). Suspensa a exigibilidade em razão da hipossuficiência presumida da pessoa natural e também constatada pela representação por advogados dativos e pela instrução processual (CPC, art. 98, § 3º, c/c CPP, art. 3º).

Registro dispensado (NSCGJ, art. 72, § 6º). Publique-se. Partes intimadas em audiência.

Sendo o caso, expeça-se certidão de honorários ao advogado dativo, em percentual compatível com a fase processual, em caso de nomeação promovida com base no convênio OAB/DPE-SP.

Transitada em julgado, expeça-se guia de execução definitiva (Resolução n. 113/2010-CNJ) e promovam-se as anotações e comunicações necessárias (CPP, art. 809), inclusive ao Tribunal Regional Eleitoral, em atenção ao art. 15, III, da CR/88, e ao Instituto de Identificação (IIRGD-SP).

Mongaguá, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA